

**Nr. 170 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches.
14. Juni 1935***R 43 I/1473, Bl. 106–122 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

An der allgemeinen Erneuerung des deutschen Strafrechts wird mit Nachdruck gearbeitet². Die endgültige Verabschiedung und Inkraftsetzung des neuen Strafgesetzbuchs, dessen Aufstellung bei der Wichtigkeit und Schwierigkeit des Stoffes keine Überhastung verträgt, ist jedoch nicht in so naher Zukunft möglich, daß die Einführung dringlicher Gesetzesänderungen bis dahin verschoben werden könnte. Es wird daher, gerade um die ruhige und zielbewußte Arbeit an der Gesamtreform nicht zu stören und diese in Ruhe reifen zu lassen, noch einmal der Weg der Novellengesetzgebung beschritten, um einige dringliche Fragen vorweg zu regeln.

Die Vorschläge, die in der Novelle zusammengefaßt sind, sollen – abgesehen von den durch die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht besonders vordringlich gewordenen Vorschriften des Artikels 3³ – teils Mißständen entgegentreten, die sich in jüngster Zeit bemerkbar gemacht haben, teils sollen sie in vorsichtiger Vorwegnahme einiger Gedanken der künftigen Gesamtreform, die schon heute als geklärt und gesichert gelten können, die Umstellung des Strafrechts auf den Geist des neuen Staates in Fortsetzung des durch die Novellen vom 26. Mai⁴ und 24. November 1933⁵ und 24. April 1934⁶ beschrittenen Weges um ein weiteres Stück vorwärtstreiben und so der im Gang befindlichen Gesamtreform den Weg bereiten und sie entlasten. Dem letzteren Zweck dienen insbesondere die das allgemeine Ziel der Auflockerung der Strafrechtspflege, der Durchsetzung der materiellen Gerechtigkeit und einer stärkeren Sicherung der Volksgemeinschaft verfolgenden Vorschläge in Art. 1 und 2 (Rechtsschöpfung durch entsprechende Anwendung der Strafgesetze und Verhütung ungerechter Freisprechungen durch Zulassung der Wahlfeststellung), dem Ziel der Abstellung bestimmter Einzelmißstände alle übrigen Vorschläge dieses Entwurfs.

Artikel 1.

¹ Mit GesEntw. auch überliefert in: R 43 II/1514, Bl. 194–216; R 22/862, Bl. 347–369. Zu den Einzelbestimmungen der geplanten Novelle s. Dok. Nr. 116, zu ihrem Stellenwert im Zuge der Strafrechtsverschärfungen seit 1933: GRUCHMANN, Justiz, S. 847–855; WERLE, Justiz-Strafrecht, S. 141 ff. Gleichzeitig mit dieser Vorlage wurde der Entwurf einer Strafprozeßnovelle im Kabinett eingebracht: Dok. Nr. 171.

² Vgl. Dok. Nr. 126.

³ Art. 3 *Verletzung der Wehrpflicht und der Wehrkraft* war nach Einführung der allgemeinen Wehrpflicht im März 1935 auf Verlangen des RKRm nachträglich eingearbeitet worden. Er ahndete die verbotene Auswanderung vor und nach Erfüllung der Dienstpflicht, die Verleitung von Soldaten zur Fahnenflucht, die Anwerbung für ein ausländisches Heer, die Selbstverstümmelung sowie die betrügerische Wehrpflichtentziehung und führte auch den Tatbestand der Wehrmittelbeschädigung in das Strafrecht ein; Entwurfsarbeiten s. R 22/862, Bl. 130–155. Ebenfalls gegenüber der Erstvorlage neu eingefügt war auch Art. 4 *Gefährdung des Eisenbahnverkehrs, der Schifffahrt oder der Luftfahrt*.

⁴ Gesetz zur Abänderung strafrechtlicher Vorschriften vom 26. 5. 33 (RGBl. I S. 295); s. ARHI/1, Nr. 125 P. 4, 134 P. 7. Hauptinhalt: Verschärfung der Vorschriften über Untreue, Betrug und leichtfertige Denunziation. Zu diesem und den nachfolgend genannten Gesetzen auch GRUCHMANN, Justiz, S. 833–847; WERLE, Justiz-Strafrecht, S. 77–134.

⁵ Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung (RGBl. I S. 995); s. ARH I/2, Nr. 244 P. 10: Möglichkeit der Strafverschärfung über das gerichtlich verhängte Strafmaß hinaus und Einführung der Sicherungsverwahrung bis auf Lebenszeit für rückfällige und besonders gewalttätige Gewohnheitskriminelle, Zulassung der Entmannung für Sittlichkeitsverbrecher.

⁶ Gesetz zur Änderung von Vorschriften des Strafrechts und des Strafverfahrens (RGBl. I S. 341); s. ARH I/2, Nr. 314, 323 P. 5, 324: Neugestaltung und Verschärfung der Vorschriften über den Hoch- und Landesverrat.

Rechtsschöpfung durch entsprechende Anwendung der Strafgesetze.

Das geltende Strafgesetzbuch läßt die Bestrafung einer Tat nur dann zu, wenn ihre Strafbarkeit im Gesetz ausdrücklich festgelegt ist. Dieser Rechtssatz (*nullum crimen sine lege*) galt in der liberalistischen Zeit als so grundlegend, daß er sogar in die Weimarer Verfassung⁷ aufgenommen wurde. Im nationalsozialistischen Strafrecht kann er diese Bedeutung nicht mehr beanspruchen. Vielmehr muß nach nationalsozialistischer Auffassung jeder strafwürdige, durch Taten in Erscheinung getretene Wille seine Ahndung finden, gleichviel, ob die Tat den Wortlaut einer Strafvorschrift genau erfüllt oder nicht. Der strafrechtliche Schutz gegen strafwürdiges Verhalten darf nicht daran scheitern, daß das geschriebene Gesetz Maschen oder Lücken aufweist, durch die der geschickte Verbrecher hindurchzuschlüpfen weiß. Nicht die Sicherheit des Verbrechers vor verdienter Strafe, sondern die Sicherung der Volksgemeinschaft gegen jeden verbrecherischen Angriff muß das Ziel der Strafrechtspflege sein.

Es genügt deshalb nicht, wie bisher nur dann zu strafen, wenn das Gesetz die begangene Tat mit Strafe bedroht, denn das Gesetz wird immer eine nur unvollkommene Aufzählung der gegen die völkische Lebens- und Friedensordnung verstoßenden Handlungen bleiben. Bei der Vielseitigkeit des Lebens kann der Gesetzgeber nicht alle Wege übersehen und voraussehen, auf denen verbrecherische Elemente sich an der Volksgemeinschaft vergehen. Dem Richter muß daher die Möglichkeit gegeben werden, bei der Aburteilung einer Tat über die Grenzen der gesetzlichen Tatbestände hinauszugehen und so der verständnisvolle Verbündete des Gesetzgebers zu werden. Nur so kann wahre Gerechtigkeit ihre Verwirklichung finden, jedes der Volksgemeinschaft zugefügte Unrecht die ihm zukommende Ahndung erfahren. Die Lockerung der bisherigen Bindung des Richters an das Strafgesetz, die hiernach geboten ist, darf allerdings nicht der Willkür des Richters Tür und Tor öffnen. Eine derartige Gefahr besteht jedoch nicht, da die heute gegebene Einheit der Weltanschauung dem Richter die sichere Richtschnur für den Geist gibt, in dem er die ihm zugewiesene neue Machtbefugnis anzuwenden haben wird. Diese Einheit der Weltanschauung ermöglicht es dem Richter, als einheitliche Quelle und Grundlage des Strafrechts wie des Rechts überhaupt die völkische Rechts- und Friedensordnung zu erkennen. Als erste und vornehmste Erkenntnisquelle ihres rechtlichen Willens wird der Richter wie bisher das Gesetz anzuerkennen haben; neben das einzelne Strafgesetz aber tritt als weitere Rechtsquelle der Rechtsgedanke, der ihm – vielleicht unvollkommen zum Ausdruck gelangt – zugrunde liegt, in Verbindung mit der gesunden Volksanschauung: Erfordert dieser Rechtsgedanke und die gesunde Volksanschauung Strafe in einem Falle, auf den das Gesetz unmittelbar sich nicht anwenden läßt, so soll der Richter künftig ebenfalls befugt sein, Strafe auszusprechen.

Daher gestattet § 2⁸ die Überschreitung solcher Grenzen,

– 1.

wenn der einem Strafgesetz zugrunde liegende Rechtsgedanke auch für den zur Entscheidung stehenden Fall in der Weise zutrifft, daß auch dieser aus demselben Grundgedanken heraus Bestrafung erfordert und

– 2.

wenn auch nach der gesunden Volksanschauung die Tat Strafe verdient.

Hierbei wird besonderer Beachtung bedürfen, daß der einem Strafgesetz zugrunde liegende Rechtsgedanke vielfach eine vom Gesetzgeber *gewollte* Begrenzung enthält. Die Überschreitung solcher

⁷ Art. 116 WRV.

⁸ § 2 StGB wurde durch die Vorlage wie folgt neu gefaßt: „Bestraft wird, wer eine Tat begeht, die das Gesetz für strafbar erklärt oder die nach dem Grundgedanken eines Strafgesetzes und nach gesunder Volksanschauung Bestrafung verdient. Findet auf die Tat kein bestimmtes Strafgesetz unmittelbar Anwendung, so wird die Tat nach dem Gesetz bestraft, dessen Grundgedanke auf sie am besten zutrifft.“

Die Wendung „gesunde Volksanschauung“ wurde überall dort, wo sie in den beiden Novellenentwürfen auftauchte, in der endgültigen Formulierung ersetzt durch „gesundes Volksempfinden“. Zur Fassung des Erstentwurfs vgl. Dok. Nr. 116 Anm. 6.

Grenzen gestattet § 2 nicht. Eine solche Begrenzung liegt vor, wenn die Beschränkung eines gesetzlichen Tatbestandes nicht darin ihren Grund hat, daß der Gesetzgeber die Fülle der Möglichkeiten des Lebens nicht hat voraussehen können, sondern darin, daß er aus staats- oder kriminalpolitischen Gründen den gesetzlichen Tatbestand bewußt eng begrenzt hat, wie etwa in § 175 StGB, wo nur die gleichgeschlechtliche Unzucht zwischen *Männern* mit Strafe bedroht wird⁹. Ebenso würde es dem erklärten Willen des Gesetzes widersprechen, Altersgrenzen, wie sie etwa § 182 StGB vorsieht, zu überschreiten¹⁰. Feste Altersgrenzen beruhen regelmäßig darauf, daß der Gesetzgeber der Rechtssicherheit bewußt den Vorzug vor anderen Rücksichten geben will. Besonders häufig werden bewußt gezogene Grenzen auf dem Gebiet der strafrechtlichen Nebengesetze Beachtung fordern.

Bei der vom Entwurf zur Sicherung gegen mißbräuchliche Anwendung vorgeschriebenen Feststellung, daß die Tat auch nach der gesunden Volksanschauung Bestrafung verdient, wird zu beachten sein, daß die gesunde Volksanschauung sich nicht unbedingt mit der Anschauung der großen Mehrheit der Volksgenossen zu decken braucht. Die Feststellung der Übereinstimmung mit der gesunden Volksanschauung ist eine *wertende* Feststellung. Gewisse laxer Anschauungen, wie sie sich z.B. in der Zeit der Geldentwertung herausgebildet hatten, können selbst dann nicht als gesunde Volksanschauung bezeichnet werden, wenn sie sich mit der Anschauung der Mehrheit decken sollten.

Ist der Richter jedoch zu der Überzeugung gekommen, daß eine Tat, die das Gesetz nicht ausdrücklich für strafbar erklärt, nach dem Grundgedanken eines Strafgesetzes und nach gesunder Volksanschauung Bestrafung verdient, so ist gemäß § 2 Satz 2 des Entwurfs die Tat nach dem Gesetz zu bestrafen, dessen Grundgedanke auf die Tat zutrifft, bzw. wenn der Grundgedanke mehrerer Gesetze zutreffen sollte, aus dem Strafraum des Gesetzes, dessen Grundgedanke auf die Tat am besten zutrifft. Durch ein besonderes, das Verfahrensrecht änderndes Gesetz¹¹ wird einerseits dafür gesorgt werden, daß die Strafjustizbehörden von der neuen Handhabe, der Gerechtigkeit zum Siege zu verhelfen, ausreichend Gebrauch machen, andererseits der Gefahr entgegentreten werden, daß die neue dem Richter gegebene Möglichkeit rechtsschöpferischer Tätigkeit zu einer Rechtszersplitterung führt.

[...]

Artikel 2.

Verhütung ungerechter Freisprechungen durch Zulassung der Wahlfeststellung.

Eine Verurteilung setzt in der Regel voraus, daß der Angeklagte einen bestimmten Tatbestand erfüllt hat, auf den alle gesetzlichen Merkmale einer bestimmten Strafvorschrift zutreffen. Bisweilen läßt sich aber der Sachverhalt nicht vollkommen aufklären; es läßt sich zwar feststellen, daß der Angeklagte sicher gegen das eine oder das andere von mehreren Strafgesetzen verstoßen hat, nicht aber, daß sämtliche Tatbestandsmerkmale erfüllt sind, an die ein bestimmtes Strafgesetz die Strafe knüpft. Ist beispielsweise sicher, daß der Angeklagte ein Eigentumsvergehen begangen hat, läßt sich aber nicht feststellen, ob dieses Vergehen ein Diebstahl oder eine Hehlerei ist, so entsteht die Frage, ob der Angeklagte freizusprechen oder ob er auf Grund einer sogenannten wahlweisen Feststellung zu verurteilen ist. Ihre Lösung blieb bisher der Rechtsprechung überlassen. Das Reichsgericht hat eine Verurteilung auf Grund wahlweiser Feststellung zwar nicht grundsätzlich abgelehnt, die Voraussetzungen für ihre Zulassung jedoch sehr eng gefaßt. Die wahlweise Feststellung sollte nur dann zulässig sein, wenn es sich lediglich um gleichwertige Ausführungsformen des gesetzlichen

⁹ Vgl. die Begründung zu Art. 6 *Unzucht zwischen Männern* (hier nicht abgedruckt): „Der neue Staat, der ein an Zahl und Kraft starkes, sittlich gesundes Volk erstrebt, muß allem widernatürlichen geschlechtlichen Treiben mit Nachdruck begegnen. Die gleichgeschlechtliche Unzucht zwischen Männern muß er besonders scharf bekämpfen, weil sie erfahrungsgemäß die Neigung zu seuchenartiger Ausbreitung hat und einen verderblichen Einfluß auf das ganze Denken und Fühlen der betroffenen Kreise ausübt.“

¹⁰ Vgl. Dok. Nr. 116 Anm. 7.

¹¹ Die gleichzeitig im Kabinett eingebrachte Strafprozeßnovelle (Anm. 1).

Tatbestandes ein- und derselben strafbaren Handlung handelte und wenn für jeden Fall dieselbe Strafe angedroht ist.

Diese Grenzziehung versagte vor allem in den bereits erwähnten praktisch wichtigen Fällen, in denen sich nicht feststellen läßt, ob der Angeklagte einen Diebstahl oder eine Hehlerei begangen hat. Um in solchen Fällen einen für das Rechtsgefühl unerträglichen Freispruch zu vermeiden, sahen sich die Gerichte vor der Notwendigkeit, in den Urteilsgründen den Anschein einer eindeutigen Feststellung des Sachverhalts auch dann zu erwecken, wenn sich eine sichere Überzeugung von der Richtigkeit der Feststellung nicht ergeben hatte. Diese Lösung ist der Gerichte nicht würdig. Das wurde vielfach empfunden und führte zu immer neuen Versuchen, die Zulässigkeit einer Wahlfeststellung schon auf dem Boden des geltenden Rechtes zu begründen.

Einen Fortschritt in dieser Richtung brachte die Stellungnahme der vereinigten Strafsenate des Reichsgerichts vom 2. Mai 1934 (RGSt.¹² Bd. 68 S. 257), die die wahlweise Verurteilung wegen Diebstahls oder Hehlerei für zulässig erklärten und damit für ein wichtiges Teilgebiet eine befriedigende Lösung ermöglicht haben. Diese Teillösung kann jedoch noch nicht genügen. Der Entwurf regelt nunmehr die Frage allgemein.

Er schreibt vor¹³, daß der Angeklagte aus dem mildesten der in Betracht kommenden Strafgesetze zu verurteilen ist, wenn zwar feststeht, daß er gegen eines von mehreren Strafgesetzen verstoßen hat, eine Tatfeststellung aber nur wahlweise möglich ist. Hier wird also eine wahldeutige Feststellung zunächst in den Fällen zugelassen, in denen es sich um eine einheitliche Tat handelt, einheitlich nicht im Sinne des materiell-rechtlichen Tatbegriffs (§§ 73, 74 StGB), sondern im verfahrensrechtlichen Sinne der Identität des historischen Vorgangs (§ 264 StPO) also um die erwähnten Fälle Diebstahl – Hehlerei, ferner Diebstahl – Unterschlagung, Unterschlagung – Untreue u. a. m.

Der Entwurf geht aber weiter. Es gibt Fälle, in denen die materielle Gerechtigkeit es verlangt, über die Schranke, die das Erfordernis der Identität der Tat darstellt, hinwegzugehen. Es hat z.B. der Angeklagte zunächst vor der Steuerbehörde eine eidesstattliche Versicherung abgegeben und dann über dasselbe Thema, aber in anderem Zusammenhang vor Gericht einen Eid geleistet, der das Gegenteil der eidesstattlichen Versicherung besagt; was richtig ist, läßt sich nicht feststellen. Auch in solchen und ähnlichen Fällen verlangt es die materielle Gerechtigkeit, daß die Täter nicht straflos ausgehen; ihnen geschieht in keinem Falle Unrecht, wenn sie aus dem mildesten der in Betracht kommenden Gesetze bestraft werden. Auch diese Möglichkeit gibt der Entwurf.

Nicht getroffen vom Entwurf werden die Fälle, in denen ein bestimmtes Strafgesetz durch eine von mehreren Handlungen verletzt ist, in denen sich aber nicht feststellen läßt, durch welche dieser Handlungen dies geschehen ist. Ein Beispiel bringt die Abwandlung des oben angeführten Falles dahin, daß es sich um zwei Eide handelt: der Angeklagte hat in einem Prozeß geschworen, er habe mit der Kindesmutter nicht verkehrt, in einem anderen Prozeß, er habe mit ihr verkehrt. Daß in solchen Fällen nicht Freispruch erfolgen darf, bedarf keiner Begründung, aber in ihnen dürfte der Richter auch ohne ausdrückliche Gesetzesbestimmung zu einer Verurteilung gelangen.

Die Erweiterung der Zulassung wahldeutiger Feststellung durch Einfügung der besprochenen neuen Vorschrift in das materielle Strafrecht macht auch zweckentsprechende neue Bestimmungen im Verfahrensrecht erforderlich, die durch die gleichzeitig vorgelegte Verfahrensnovelle vorgeschlagen werden¹⁴.

[...]

¹² Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen. Zur Sache vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 852.

¹³ Art. 2 der Novelle fügte folgenden neuen § 2b in das StGB ein: „Steht fest, daß jemand gegen eines von mehreren Strafgesetzen verstoßen hat, ist aber eine Tatfeststellung nur wahlweise möglich, so ist der Täter aus dem mildesten Gesetz zu bestrafen.“

¹⁴ S. Dok. Nr. 171, zu Art. 1 Nr. 2. – Verabschiedung des Entwurfs s. Dok. Nr. 178 P. 7a.

Zitierhinweis

Nr. 170 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches. 14. Juni 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d170>